

1500074-92.2022.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR OSVALDO VILELLA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

VICTOR OSVALDO VILELLA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1500074-92.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500074-92.2022.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR OSVALDO VILELLA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

VICTOR OSVALDO VILELLA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 09:34 horas, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06/2020), na Rua Orlando Gonçalves da Silva, nº 874, bairro São Rafael II, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 12 porções de maconha, com peso líquido total de 39,08 gramas, e 17 eppendorfs de cocaína, com peso líquido total de 5,48 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o réu (fl. 149) e apresentada defesa preliminar (fls. 153/154), a denúncia foi recebida (fls. 155/156). O acusado foi citado (fl. 195).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 196/200).

Deferida a diligência requerida pelo d. órgão acusatório, passou-se às alegações finais. Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor Público postulou a desclassificação para os delitos do art. 28 ou do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas ou, em caso contrário, a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial semiaberto (fls. 196/200).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e dos laudos de constatação provisória (fls. 14/16) e definitiva de entorpecentes (fls. 81/83 e 84/86), com resultados positivos para cocaína e THC (maconha), bem como do relatório de investigação com extração de conteúdo do celular apreendido (fls. 102/104) e do laudo de exame pericial do aparelho (fls. 105/131).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado admitiu sem rebuços sua atuação no tráfico de drogas, afirmando que na ocasião comercializava porções de entorpecentes pelo valor unitário de R\$ 10,00. Confirmou que o dinheiro apreendido era produto das vendas realizadas, sendo que na data dos fatos já havia vendido 3 porções de maconha (fl. 04).

Em juízo, porém, modificou sua versão e passou a afirmar que, na data mencionada, acabara de chegar ao local dos fatos para adquirir uma "bolsa" de cocaína e uma outra de maconha quando foi abordado por policiais militares. Tinha consigo apenas

a quantia em dinheiro de R\$ 90,00, oriunda de seu trabalho, e um celular, que foram apreendidos. Negou que comercializasse entorpecentes no momento de sua abordagem e aduziu que a bolsa apreendida era de um outro indivíduo que saíra correndo com a chegada dos policiais. Não chegou a receber as porções de drogas, que seriam destinadas ao seu próprio consumo, nem a efetuar o pagamento por elas, pois o combinado era que pagaria cerca de R\$ 100,00 ao traficante. Negou qualquer envolvimento com o narcotráfico, mas confirmou que já foi condenado por tal prática no passado. Na época do ocorrido fazia uso de cocaína e maconha e trabalhava como ajudante de pedreiro. Aduziu ter sido agredido pelos policiais e obrigado a confessar, na delegacia de polícia, a venda de drogas (cf. gravação audiovisual de fls. 196/200).

Ocorre que, apesar da versão exculpatória exarada pelo réu em juízo, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade no tocante ao delito capitulado na denúncia.

Assim é que os policiais militares Machado e Antônio relataram que, na data mencionada, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela constante prática do narcotráfico, visualizaram o acusado em uma bicicleta, em atitude suspeita. Ao avistar a aproximação da viatura policial, ele abandonou a bicicleta no local e saiu correndo, mas logo foi abordado, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Em poder do réu foi apreendida uma bolsa contendo 12 invólucros de maconha e 17 eppendorfs de cocaína, além da quantia em dinheiro de R\$ 70,00 em notas diversas e um celular (cf. gravação audiovisual de fls. 196/200).

Machado ainda acresceu que, ao ser indagado, o réu admitiu a comercialização de drogas naquele local e confirmou que o numerário era produto das vendas, alegando que na época dos fatos estava desempregado.

Antônio, por outro lado, declarou que o réu lhe disse serem as drogas apreendidas destinadas ao seu próprio consumo.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, “a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém” (RTJ 95/563), pois “é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências” (RJDTACRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Impende assentar, todavia, que a retratação manifestada em juízo pelo imputado não pode ser aceita, porquanto o restante do acervo probatório coligido durante a persecutio criminis demonstra de forma segura a sua efetiva atuação no delito em exame. Confira-se:

“PROVA – Confissão perante autoridade policial – Retratação em juízo – Irrelevância – Validade – A confissão não vale pelo local onde é apresentada, mas sim pelo seu teor de credibilidade em consonância com os demais elementos amealhados nos autos, tornando a retratação judicial insignificante” (TACrimSP – Apelação nº 761.293/0 – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – j. 17.06.1993 – RJDTACrim 22/276).

Na hipótese em exame, a conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio

ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida não apenas pela palavra do réu na fase inquisitiva (fl. 04), mas, sobretudo, pela natureza, diversidade e forma de acondicionamento dos tóxicos apreendidos (17 pinos do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido total de 5,48 gramas, e 12 porções de maconha, com peso líquido total de 39,08 gramas, já embalados e separados individualmente para a revenda e entrega a terceiros – cf. auto de fls. 11/12 e laudos de fls. 14/16, 81/83 e 84/86).

Também houve a apreensão em poder do acusado, no mesmo contexto fático, de um aparelho celular (utilizado como instrumento do crime) e de quantia em dinheiro (R\$ 70,00 em notas trocadas), certamente relacionada à prática ilícita em questão (cf. auto de fls. 11/12 e guia de fl. 80).

Note-se, a propósito, que o imputado não apresentou nenhuma prova cabal da suposta origem lícita do referido numerário, mas apenas a alegação vaga e genérica de que era proveniente de seu trabalho como ajudante de pedreiro, o que reforça a conclusão de que era mesmo oriundo da nefasta mercancia, até porque foi bem demonstrado nos autos que na época dos fatos o agente estava desempregado (cf. documentos de fls. 17 e 18/19).

No tocante ao celular utilizado pelo réu, o exame pericial realizado no aparelho revelou a existência de diversas mensagens e áudios claramente relacionados ao comércio espúrio por ele praticado desde o final do ano anterior à data dos fatos, consoante se infere do teor dos diálogos mantidos com os contatos “Adriele”, “Siniso RT”, “TU3”, “Tiu Claudio” e “R7” (cf. relatório de investigação com extração de conteúdo do celular de fls. 102/104 e laudo de fls. 105/131).

Frise-se, nesse ponto, que no aparelho em questão foram verificadas conversas relativas ao narcotráfico em diversas datas até a véspera da prisão do réu (ao menos nas datas de 28.12.2021, 29.12.2021, 10.01.2022, 12.01.2022 e 21.01.2022), a evidenciar a prática habitual e reiterada das referidas atividades ilícitas pelo imputado.

Vale ainda destacar, por oportuno, que no meio policial já havia informações dando conta da frequente prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se depreende, sobretudo, do teor dos depoimentos dos milicianos ouvidos em solo judicial.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, confirmam a ocorrência, na hipótese em apreço, da guarda e do transporte das drogas para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, ademais, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de drogas, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito – como ocorreu na espécie – as substâncias entorpecentes, sendo inexigível a tradição para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, o pleito de desclassificação delitiva formulado pela Defesa Técnica do acusado, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que os entorpecentes apreendidos eram pertencentes ao réu e se destinavam, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros – ainda que de forma gratuita –, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

É consabido, outrossim, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples 'guarda temporária' da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

De igual modo, repele-se a pretensão defensiva de desclassificação para a conduta tipificada no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas, eis que em nenhum momento os elementos de prova amealhados durante a persecução penal apontaram que as drogas apreendidas seriam oferecidas pelo réu, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos as consumirem.

Como visto, por ocasião dos fatos o imputado não estava em situação clara de consumo de droga e, além disso, encontrava-se sozinho no local dos fatos no momento da abordagem, sendo descabido, portanto, cogitar-se de um suposto compartilhamento do uso das drogas.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas ao réu.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) – caracterizada pela anterior condenação definitiva que o réu ostenta pela prática da mesma espécie de delito, retratada na certidão cartorária de fls. 201/202 – é compensada pela presença da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo codex), mantendo-se as penas, pois, no patamar inicial fixado.

Afinal, “a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, também é preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência” (STJ – Habeas Corpus nº 102.449/SP – 6ª Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 31.05.2011); e ainda: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas” (STJ – Habeas Corpus nº 341.501/MS – 6ª Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 17.12.2015 – DJe 02.02.2016).

Convém assinalar, ademais, que o fato de a reincidência do réu ser específica não altera o quadro ora apontado:

“Esta Corte fixou o entendimento de que, ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea” (STJ – Habeas Corpus nº 461.033/DF – 6ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 06.11.2018).

Não há falar-se, contudo, na incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois, embora não haja dúvida de que o crime foi cometido durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tal circunstância em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual, ausente o nexo causal, deve ser afastada a agravante em questão. Confira-se:

“Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “53. Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os

gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgraça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente dessas situações" (TJSP - Apelação nº 1510214-73.2020.8.26.0228 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Xavier de Souza - j. 14.09.2020).

Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, não há cogitar-se da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilegio), pois, como mencionado, o réu não ostenta a necessária primariedade e há nos autos prova robusta da dedicação habitual e reiterada do agente a atividades criminosas, conforme se extrai, especialmente, do conteúdo extraído do celular por ele utilizado (cf. relatório de investigação de fls. 102/104 e laudo de fls. 105/131).

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Outrossim, não obstante tenha o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012), declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), por entender que a norma contraria a CF/88, especificamente no que diz respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), para admitir a imposição, aos condenados por crimes hediondos e a eles equiparados, de regime prisional inicial diverso do fechado, o fato é que, na espécie, considerando o quantum da pena corporal, bem como a reincidência específica do réu, a nocividade de sua conduta e a acentuada periculosidade por ele demonstrada por ocasião da prática delitiva, a pena carcerária ora imposta será cumprida inicialmente em regime prisional fechado (até porque se revela o único cabível na hipótese, diante do que prevê o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).

Por fim, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a referida substituição de penas revela-se incabível, no caso em exame, tendo em vista a reincidência específica do acusado e o próprio montante da pena corporal aplicada (superior a 4 anos de reclusão), elementos que não se amoldam ao disposto no art. 44, inciso I, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu VICTOR OSVALDO VILELLA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo,

como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o acusado recorrer em liberdade, eis que subsistem íntegros os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar durante toda a persecutio criminis.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do objeto e do numerário apreendidos (cf. auto de fls. 11/12 e guia de fl. 80), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 28 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA